

1528642-69.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... guardavam e tinham em depósito, para fim de tráfico, drogas (cocaína, "crack", lança-perfume e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar", ou ainda "associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas".

Com efeito, os policiais civis Manuel, José Carlos, Rafael e Luís Fenando ouvidos em juízo, afirmaram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528642-69.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528642-69.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VITORIA DE JESUS PINHEIRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

EDNALVA AMORIM DOS SANTOS, VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO, ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS e LEONARDO MONTEIRO MOJA, conhecido por "LEO DO MOINHO", foram denunciados como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com art. 61, II, "j" e 69, "caput", do Código Penal e MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 330, combinado com art. 61, II, "j" e 69 do Código Penal.

Segundo apurado, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 21 horas, em ocasião de calamidade pública provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), na Rua Doutor Elias Chaves, na altura do nº 20, Santa Cecília ("Comunidade do Moinho"), nesta Capital, os indiciados EDNALVA AMORIM DOS SANTOS, MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS, VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO, ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS e LEONARDO MONTEIRO MOJA, conhecido por "LEO DO MOINHO", qualificados às fls. 35, 36/37, 38, 39/40, 41/42, 43/44 e 277, respectivamente, associados, preparavam, guardavam e tinham em depósito, para fim de tráfico, drogas (cocaína, "crack", lança-perfume e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que em período não apurado com precisão, de maio de 2021 até o dia 25 de novembro de 2021, em ocasião de calamidade pública provocada pelo novo

coronavírus (COVID-19), na Rua Doutor Elias Chaves, na altura do nº 20, Santa Cecília ("Comunidade do Moinho") e na "Cracolândia", 20, Santa Cecília ("Comunidade do Moinho") e na "Cracolândia", nesta Capital, os indiciados EDNALVA AMORIM DOS SANTOS, MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS, VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO, ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS e LEONARDO MONTEIRO MOJA, conhecido por "LEO DO MOINHO", associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas.

Por fim é dos autos, ainda que no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 21 horas, em ocasião de calamidade pública provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), na Rua Doutor Elias Chaves, na altura do nº 20, Santa Cecília ("Comunidade do Moinho"), nesta Capital, o indiciado MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS também se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. A denúncia foi recebida, os réus foram citados, notificados e apresentaram resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, afastadas todas as alegações das Defesas, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos os policiais civis Manuel, José Carlos e Rafael e as testemunhas Cláudio, Mayara, Percília, Victor, Jeferson, Thauane. A Defesa do réu Leonardo insistiu na oitiva do policial Luis Fernando, bem como na oitiva presencial de dois policiais atuantes na Baixada Santista. (fls. 736/738). As outras partes desistiram da oitiva das testemunhas faltantes o que foi devidamente homologado.

Deferido o pleito do combativo Defensor designou-se nova audiência presencial, na qual foram ouvidas as testemunhas faltantes e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, as partes se manifestaram em memoriais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A questão preliminar arguida pela defesa do acusado Leonardo já foi devidamente analisada por este juízo, e conforme afirmado pelo próprio advogado está pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça, órgão competente para analisá-la. Assim sendo, nada a decidir.

No mérito propriamente dito no que toca ao réu Leonardo, de fato, como muito bem ponderado pelas partes não há provas de sua participação nos delitos narrados na denúncia.

Isso porque, não se logrou êxito comprovar durante a instrução criminal que o acusado Leonardo juntamente com os demais acusados "preparavam, guardavam e tinham em depósito, para fim de tráfico, drogas (cocaína, "crack", lança-perfume e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar", ou ainda "associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas".

Com efeito, os policiais civis Manuel, José Carlos, Rafael e Luís Fenando ouvidos em juízo, afirmaram que após diversas investigações e com a prisão de alguns indivíduos pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, chegou-se a conclusão de que um indivíduo de alcunha "Léo do Moinho" era o responsável direto pela comercialização de drogas na comunidade referida e diante disso e ainda da informação do local exato em que as drogas eram preparadas as drogas para venda para lá se dirigiram e conseguiram prender alguns indivíduos e várias porções de drogas e um caderno onde havia o prenome "Léo".

Eles afirmaram, ainda que não foi possível se comprovar que esse Léo era realmente a pessoa de Leonardo Monteiro Moja.

Os outros dois policiais que fizeram a prisão do réu Leonardo apenas disseram que foram ao local em que ele residia, após receberem uma denúncia anônima e lá constataram que Leonardo era procurado pela justiça e por isso foi preso.

Disseram que não sabiam quem era "Léo do Moinho".

Ora, em face dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, outra solução não há senão a absolvição do réu. Isso porque, o que temos de concreto, não nos permite afirmar com certeza de que a ré cometeu os delitos pelos quais está sendo processada, já que não é dado ao magistrado presumir a autoria do crime imputado ao réu na denúncia.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e,

mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348). Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu. Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria do crime, a solução absolutória é que se impõe. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA INCERTA - ABSOLVIÇÃO. Não restando devidamente comprovada a autoria, a absolvição é medida que se impõe, porque em processo penal a dúvida caminha em favor do réu. Provimento do recurso que se impõe". (TJ-MG - APR: 10172090207546001 Conceição das Alagoas, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 15/06/2010, Câmaras Criminais Isoladas / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2010).

Aliás, no que toca ao crime de associação para o tráfico, imposta a todos os réus na denúncia, como bem ponderado pelas partes, há que se ressaltar que não há provas suficientes para a condenação de quaisquer dos acusados. Como é sabido, necessário se faz para a configuração do delito em questão prova de estabilidade e de vínculo permanente dos envolvidos o que efetivamente não veio comprovado nos autos em tela.

Como ensina Vicente Greco Filho, a associação criminosa exige a presença do ânimo associativo, ou seja, "de um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado" (Tóxicos, 1979, p.104).

Assim embora os réus tenham sido encontrados todos no mesmo barraco preparando os entorpecentes não há nos autos elementos suficientes que indiquem a associação mencionada e diante disso outra solução não há que também a absolvição dos corréus com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Já no que toca ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, outra sorte lhes convém, já que para este juízo, as provas colhidas sob o crivo do contraditório são suficientes para embasar a condenação dos acusados.

De fato, os policiais que prenderam os réus Ednalva, Vitória, Allan, Márcio e Júlia afirmaram que durante as várias investigações que estavam sendo feitas foi possível identificar a "casa bomba", local em que os traficantes armazenam, embalam e preparam as drogas para serem comercializadas e de posse da localização para lá se dirigiram e conseguiram prender todos os réus que estavam próximos a uma mesa preparando e embalando os entorpecentes que foram devidamente apreendidos. As testemunhas ouvidas não estavam presente no local em que os réus foram presos e apenas afirmaram não ter conhecimento de que eles seriam traficantes.

Os réus, por sua vez, à exceção de Matheus e de Ednalva, disseram que foram ao local apenas para comprar drogas e que quando a polícia chegou foi um corre corre e acabaram sendo presos. Negaram que estivessem no local embalando e preparando as drogas.

Matheus confessou o crime de tráfico e disse que estava na parte de fora do barracão, vendendo drogas que pertenciam a Daniel. Afirmou que estava desempregado e que precisava de dinheiro para sustentar sua família e que por isso aceitou vender entorpecentes. Confirmou, ainda, que já havia sido preso anteriormente no mesmo local também comercializando entorpecentes. Negou, contudo ter agredido o policial.

Ednalva, por sua vez, disse que estava no local dos fatos à procura de seu filho que é usuário de drogas e que ele não foi por ela encontrado e no momento em que ia embora a polícia entrou no barraco e prendeu várias pessoas.

Pois bem a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes veio devidamente corroborada nos autos em especial pelo laudo de fls. 553/556, que atestou a presença de substâncias entorpecentes.

O tráfico também veio devidamente comprovado, com efeito, as narrativas dos

policiais foram unânimes no sentido de que havia muitas pessoas no local e que foram presos aqueles que estavam preparando a droga e se encontravam atrás da mesa onde as drogas e os petrechos foram encontrados.

Ora, nesse contexto e ainda considerando todo material apreendido durante a prisão dos réus, ou seja, 212 porções de "crack"., 08 frascos de lança-perfume; 20 porções de maconho e 209 porções de cocaína e os objetos apreendidos e periciados a fls.759/789, as fotografias anexas e ainda, os depoimentos dos policiais no sentido de que todas as pessoas que foram presas estavam atrás da mesa em que as drogas estavam preparando os entorpecentes já são suficientes para a condenação dos acusados.

E neste ponto com todo o respeito as alegações das partes no sentido de que a exceção de Matheus que confessou o crime de tráfico os demais eram apenas usuários, tal fato para este juízo, não veio comprovada por outras provas.

Note-se que quantidade e a variedade de droga apreendidas, o dinheiro encontrado, um caderno com anotações de venda de entorpecentes, todos os petrechos e ainda o local em que todos os acusados foram apreendidos, e o fato de que todos foram presos atrás da mesa onde os entorpecentes estavam, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, muito embora tenha o réu tentado caracterizar de tal forma.

Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida nestes autos se deu após minuciosa investigação que culminou na localização da "casa bomba", sem que haja qualquer indício de perseguição pelos policiais em relação aos acusados. Assim é que a versão dos acusados no sentido de que são meros usuários de drogas e que foram presos no momento em que estavam comprando entorpecentes, não foi corroborada nos autos.

Também com relação ao corréu Matheus, comprovado está nos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele se opôs à execução de ato legal, mediante violência à funcionário público competente para executá-lo.

Com efeito o policial Rafael Rodrigues nas duas ocasiões em que foi ouvido foi categórico em afirmar que foi ao local dos fatos identificado como "casa bomba" e ao tentar deter o acusado Matheus entrou em luta corporal e foi agredido com uma mordida no braço, o que veio devidamente comprovado pelo exame de corpo de delito juntado a fls. 944/945.

Nesse sentido:

TJSP: "o acusado que resiste a prisão e entra em luta corporal com policial, agredindo-o e ferindo-o, comete o crime previsto no art. 329 do Código Penal" (RT 834/553).

Ressalta-se apenas para se afastar qualquer alegação de omissão na sentença, que embora o Ministério Público tenha capitulado o crime cometido pelo réu no art. 330, do Código Penal, o réu se defende dos fatos e consoante se verifica da denúncia o crime narrado foi o de resistência previsto no art. 329, do Código Penal.

Por fim não há que se falar em agressão física por parte dos policiais comprovada nos autos, isso porque todos disseram que havia muitas pessoas no local e que houve uma confusão generalizada com a chegada da polícia e que alguns dos acusados acabaram se ferindo no momento em que tentavam escapar da detenção. Veja-se que os próprios policiais confirmaram que havia escada no local e que uma das rés caiu ao chão.

Caracterizadas, portanto, as infrações penais a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena de cada acusado:

Da ré Vitoria de Jesus Pinheiro:

A ré é primária e não possui antecedentes criminais atestados nos autos consoante certidão de fls. 137.

Assim sendo a pena base será mantida no mínimo legal de 05 anos de 500 dias-multa. Na segunda fase de aplicação de pena, há que se considerar que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020 e ainda a menoridade relativa da ré apontada a fls. 38, que neste caso se compensam devendo assim a pena ser mantida no mínimo legal estabelecido.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena para serem levadas em conta. Por outro lado, como não há prova de que a acusada pertença à organização criminosa, nem tampouco de que se dedique a atividades criminosas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzida em 2/3, chegando-se ao total de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Da ré Ednalva Amorim dos Santos:

A ré é primária e não possui antecedentes criminais atestados nos autos consoante certidão de fls. 139.

Assim sendo a pena base será mantida no mínimo legal de 05 anos de 500 dias-multa. Na segunda fase de aplicação de pena, há que se considerar que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, não obstante posições em contrário, há que asseverar que para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Ainda mais na época em que os fatos ocorreram, já que estava chegando ao Brasil uma nova variante do vírus, a ômicron que já começava a matar inúmeras pessoas. Assim sendo, a pena deve ser agravada em mais 1/6, alcançando o patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante

período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- “O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.”

O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população

foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia. Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

A 9ª Câmara Criminal, também assim se manifestou em voto proferido pela Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II,

alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la".

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena para serem levadas em conta. Por outro lado, como não há prova de que o acusado pertença à organização criminosa, nem tampouco de que se dedique a atividades criminosas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzida em 2/3, chegando-se ao total de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Do réu Márcio José dos Santos:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos consoante certidão de fls. 153.

Assim sendo a pena base será mantida no mínimo legal de 05 anos de 500 dias-multa. Na segunda fase de aplicação de pena, há que se considerar que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, Neste ponto, como acima ressaltado não há que se falar em afastamento da referida agravante, consoante entendimento desta magistrada, devendo a pena ser aumentada em 1/6, perfazendo 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena para serem levadas em conta. Por outro lado, como não há prova de que o acusado pertença à organização criminosa, nem tampouco de que se dedique a atividades criminosas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzida em 2/3, chegando-se ao total de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Da ré JULIA THAISSA LIMA DOS SANTOS:

A ré é primária e não possui antecedentes criminais atestados nos autos consoante certidão de fls. 152, apesar de já ter sido processada em duas oportunidades perante a Vara da Infância e Juventude por prática de ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes consoante certidão de fls. 151.

Assim sendo a pena base será mantida no mínimo legal de 05 anos de 500 dias-multa. Na segunda fase de aplicação de pena, há que se considerar que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020 e ainda a menoridade relativa da ré apontada a fls. 43, que neste caso se compensam devendo assim a pena ser mantida no mínimo legal estabelecido.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem levadas em conta, por outro lado, considerando que a acusada tem 02 passagens pela Vara da Infância, por ter cometido ato infracional equiparado a tráfico ilícitos de entorpecentes, não há que se falar em aplicação do disposto no do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, já que comprovado está que Júlia se dedica a atividade criminosa.

Neste sentido: "O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa" (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Ausentes outras causas modificadoras torno essa pena de 05 anos de reclusão e 500 dias definitiva.

Do réu Allan Aparecido da Luz dos Santos:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, já que ainda pendente de julgamento a decisão de primeiro grau que o condenou pelo crime de trafico. (autos 1501066-04.2021.8.26.0228- fls. 149), e diante disso a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase há que se reconhecer a agravante prevista no art.61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020 e a menoridade relativa atestada a fls. 39/40. Assim sendo, a pena não

sofrerá qualquer alteração.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem levadas em conta, por outro lado, verifica-se a fls. 148 que o réu já foi diversas vezes processado perante a Vara da Infância e Juventude, por prática reiterada de ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes, tendo cumprido várias vezes medida socioeducativa.

Desse modo, como acima ressaltado na aplicação da pena da corréu Júlia, não há que se falar em aplicação do disposto no do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06.

Do réu Matheus da Luz dos Santos:

Do crime de tráfico:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, já que ainda pendente de julgamento a decisão de primeiro grau que o condenou pelo crime de tráfico. (autos 1501066-04.2021.8.26.0228- fls. 149), e diante disso a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase há que se reconhecer a agravante prevista no art.61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020 e também a atenuante da confissão já que o acusado ao ser interrogado disse que realmente estava no local vendendo entorpecentes. Assim sendo, a pena não deve ser alterada já que atenuante e agravante se compensam.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem levadas em conta, por outro lado, embora primário o réu já foi condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes perante a 8ª Vara Criminal, fato este por ele confirmado em juízo.

Nesse ponto, embora ainda não haja o trânsito em julgado da referida decisão, fato é que ao ser beneficiado com a liberdade provisória naqueles autos o réu novamente voltou ao mesmo local, segundo ele próprio afirmou e lá, mais uma vez, se colocou a vender drogas o que demonstra que faz do tráfico ilícito de entorpecentes sua atividade laboral, não devendo assim ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Do crime de resistência:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, já que ainda pendente de julgamento a decisão de primeiro grau que o condenou pelo crime de tráfico. (autos 1501066-04.2021.8.26.0228- fls. 149), e diante disso a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 02 meses de detenção.

Na segunda fase há que se reconhecer a agravante prevista no art.61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, por todos os motivos já expostos e assim sendo a pena deve ser aumentada em 1/6, perfazendo 02 meses e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a se considerar.

Os dois delitos foram praticados em concurso material e assim sendo a pena deve ser somada, totalizando 05 anos, 02 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade e 500 dias-multa, que deverá ser executada nos moldes do que dispõe o art. 76, do Código Penal.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente ação penal que a Justiça Pública para absolver os réus EDNALVA AMORIM DOS SANTOS, MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS, VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO, ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS, da imputação prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; absolver o réu LEONARDO MONTEIRO MOJA, de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e para condenar EDNALVA AMORIM DOS SANTOS e MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS cada qual à pena de 01

ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, , VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa; como incusos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS e JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS cada qual a 05 anos de reclusão e 500 dias multa, como incurso no art. 33 "caput" da lei 11.343/06 e MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 05 anos, 02 meses e 10 dias e ao pagamento de 500 dias-multa, por estar incurso no art. 3, "caput", da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 329, "caput", combinado com art.69, "caput", ambos do Código Penal.

do Código Penal e

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com relação ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 os réus MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS, ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS e JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS cumprirão a pena em regime inicial fechado.

Já para o crime de resistência cometido pelo réu MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, notadamente pela quantidade de pena aplicada.

Quanto aos corréus EDNALVA AMORIM DOS SANTOS, VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO e MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, que foram condenados por tráfico privilegiado, JÚLIA THAISSA LIMA DOS SANTOS, em face das decisões reiteradas das cortes superiores, e, sobretudo, pelo fato de que os acusados são primários, e que o crime por eles não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ainda considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

No mais, quanto a estes três réus nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, que fica ora estabelecida por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e que deverá ser determinada no Juízo da Execução.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar o réu o "sursis".

Em razão da pena aplicada, concedo aos três acusados o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se com urgência alvará de soltura com relação aos corréus EDNALVA AMORIM DOS SANTOS e MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, com urgência.

Com relação a ré VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO, considerando a pena que lhe fora aplicada revogo a medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente a ela imposta.

Oficie-se a Secretaria da Administração Penitenciária para que promova a remoção do equipamento, com urgência.

Já com relação aos corréus MATHEUS DA LUZ DOS SANTOS e ALLAN APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, mantenho a prisão cautelar anteriormente aplicada, com fulcro no disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, aliás, considerando que já respondem presos a este processo, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destarte, não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

Por quanto à ré Júlia, considerando que foi solta por este processo e que não há nos autos elementos concretos para que sua liberdade seja revogada, na presente data, sendo, poderá recorrer em liberdade. Mantém-se contudo a medida cautelar de monitoramento eletrônico até o trânsito em julgado da presente sentença.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Decreto a perda do dinheiro apreendido, em favor da União, nos termos legais. Determino, ainda, se o caso destruição de toda droga apreendida, inclusive eventual quantia guardada para contraprova, nos termos legais.

Condeno ainda todos os réus ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderão os condenados, caso demonstrem preencher a hipótese legal, nos termos do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, se valerem de tal benefício, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA